

刑事訴訟法第321条第3項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定し、同条第4項は、「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。」と規定する。これらの規定に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例に照らして誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 同条第3項所定の書面には、捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載した書面も含まれる。

イ. 警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書は、選別に立ち会った司法警察員が臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることを証言によって明らかにすれば、同条第3項により証拠能力を付与される。

ウ. 酒酔い鑑識カードは、被疑者との問答欄であっても、被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として、被疑者の状態につき検査、観察により認識した結果を記載したものであるから、同条第3項の書面にあたる。

エ. 捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について、実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には、同条第3項所定の要件が満たされれば証拠能力が付与される。

オ. 捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書には、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に關する同条第4項が準用される。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 正しい

最判昭 35.9.8 (百選 A38 事件)。判例は、「刑訴 321 条3項所定の書面には捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、第1に、検証が強制処分として行われるとしても、任意処分として行われるとしても、事物の形状、現象を五官の作用によって直接実験、認識するものであることの性質に相違はなく、またその結果を記載した書面の方が口頭による報告よりも正確に了解させ得ることにも相違はないということ、第2に、令状の有無が検証者の観察と記述とを注意深くなさせ、正確ならしめることに関係や保証を有するものとは解されないということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

最決昭 62.3.3 (百選 62 事件)。判例は、警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書の証拠能力につき、「選別につき専門的な知識と経験を有する指導手が、臭気選別能力が優れ、選別時において体調等も良好でその能力がよく保持されている警察犬を使用して実施したものであるとともに、臭気の採取、保管の過程や臭気選別の方法に不適切な点のないことが認められる」場合において、臭気選別の結果を有罪認定の用に供しうることを認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、警察犬による臭気選別結果の信頼性が一般的に乏しいとはいえないこと、及び、判例の掲げる諸点が立証されるならば、証拠としての関連性を肯定できるということを挙げている。

また、判例は、伝聞例外の根拠条文につき、「右の各臭気選別の経過及び結果を記載した本件各報告書は、右選別に立ち会った司法警察員らが臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることが、右司法警察員らの証言によって明らかであるから、刑訴法 321 条3項により証拠能力が付与される」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、第1に、321 条3項所定の書面には、捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載した実況見分調書をも包含するとされていること (最判昭 35.9.8) を前提とすると、臭気選別に立ち会った警察官が指導手の行った検査の経過と結果をありのままに記載した書面については、実況見分調書の一種として、321 条3項により証拠能力を認めるべきであるということを挙げている。加えて、第2に、そのように解しても、被告人とすれば、関連性の関係で指導手を、また、作成の真正の関係で作成者である警察官を証人として喚問でき、反対尋問によって信頼性、正確性等につき吟味できるのであるから、被告人にとって防御上の支障を生ずるものとはいえないということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

最判昭 47.6.2。判例は、「本件『鑑識カード』のうち被疑者との問答の記載のある欄は、同巡査が所定の項目につき質問をしてこれに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり、必ずしも検証の結果を記載したものというだけではできず、……同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして、刑訴法 321 条1項3号の書面にあたる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、321 条3項の適用を受け得るためには、その記載がある程度詳細であることが前提となるが、本件鑑識カードの問答の記載はいささか簡単に過ぎるということを挙げている。したがって、本記述は、酒酔い鑑識カードのうち被疑者との問答欄は、必ずしも 321 条3項の書面にあたるとはいえないとすべきところ、当たるとしている点で、誤っている。

なお、酒酔い鑑識カードのうち被疑者との問答欄については、322 条1項の書面にあたるのではないかも問題となり得る。この点については、酒酔い鑑識カードに記録されている被疑者との問答は、もともと被疑者の供述内容を証拠に供しようとする取調べ (198 条) ではなく、被疑者の酒酔いの程

度を知るための一資料として、質問に対する被疑者の応答状況をありのままに知ろうとするものであるから、問答の記載は、本来、322条1項の適用を受ける被疑者の供述調書たることを予定するものではないということが指摘されている。

エ 誤っている

最決平17.9.27(百選82事件)。判例は、本記述と同様の実況見分調書の証拠能力について、「刑訴法326条の同意が得られない場合には、同法321条3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、再現者の供述の録取部分及び写真については、再現者が被告人以外の者である場合には同法321条1項2号ないし3号所定の、被告人である場合には同法322条1項所定の要件を満たす必要があるというべきである。もっとも、写真については、撮影、現像等の記録の過程が機械的操作によってなされることから前記各要件のうち再現者の署名押印は不要と解される」としている。

判例の結論に賛成する学説は、その理由として、まず被疑者の供述録取部分については、いわゆる現場供述にあたるから、321条3項の要件のみでは証拠能力を取得せず、通常の供述録取書と同様の要件が必要であるということを挙げている。また、上記学説は、写真部分については、立証の直接の対象が再現されたとおりの犯罪事実の存在と認められる場合には、再現者の再現行為は、言葉に代えて動作によって犯行態様がどのようなものであったかを説明するものに過ぎず、実質においていわゆる現場供述とみるほかないから、そのような再現行為を撮影した写真は、供述写真ともいうべきものであり、同写真が証拠能力を取得するためには、再現者の供述録取部分と同様の証拠能力が必要であるということを挙げている。したがって、本記述は、捜査官が被疑者に犯行再現状況を再現させた結果を記録した実況見分調書は、実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には、321条3項所定の要件だけでなく、322条1項所定の要件をも満たさなければ証拠能力を取得しないとすべきところ、321条3項所定の要件が満たされれば証拠能力が付与されるとしている点で、誤っている。

オ 正しい

最判昭28.10.15(百選A39事件)。判例は、「捜査機関の嘱託に基く鑑定書(刑訴223条)には、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する刑訴321条4項を準用すべきものである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、鑑定の内容は極めて複雑であるため、記憶に基づく口頭での報告を求めるよりも、書面を前提とした上で証人尋問を行う方が、かえって、その正確性の吟味に資するということを挙げている。したがって、本記述は正しい。